<의약용도발명>

(약속의용/용시)

물질이 가지는 특정의 약리효과라는 속성의 발견에 기초하여 의약으로서의 효능을 발휘하는 새로운 용도를 제공하는 발명. 새로운 용도를 개발하기 위해 오랜 기간의 시험에 따른 비용과 노력이 소요되는 점에서 용도의 개발을 특허로써 보호한다.

(약불내/용특구자한구)

약리기전은 특정물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소로 볼 수 없다.

(용구개/통용약구개)

의약용도가 선행발명에 의해 구체적으로 개시되었는지 여부에 의해 신규성 유무가 결정된다고 판시하며, 선행발명이 통상의 기술자가 의약용도와 관련한 약리효과를 객관적으로 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있는 경우에 신규성이 부정된다고 본다.

(치쉽예정/선임확요없)

i) 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, ii) 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

(전특데시완명)

출원 전 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않는 이상 특정물질에 약리효과가 있다는 것을 데이터 등이 기재된 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서 기재요건을 충족한다.

(개약공병약명)

화합물의 활성성분에 대한 개별적인 약리기전이 공지되었다는 사실만으로는 화합물의 병용사용에 따른 약리기전이 명확하게 밝혀졌다고 볼 수 없다.

(청용/대질약명/약만발상)

의약용도가 발명의 구성요건에 해당하므로 청구범위는 특정물질의 의약용도를 대상질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다. 다만, 특정물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서 다른 기재나 기술상식에 의해 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우 명확성 요건을 충족한다.

(특구포/용주부포)

용도발명에 관한 특허침해가 성립되기 위해서는 침해제품이 특정물질을 구성성분으로 포함하고 있다는 점 뿐 아니라 특정 용도를 그 주된 용도 또는 부수적 용도로 포함하고 있다는 점까지 인정되어야 한다.

(명제포효광)

명세서 기재, 침해제품이 속하는 제품군의 일반적인 기능과 용도, 포장지·포장용기 등에 표기된 침해제품의 효능, 침해제품에 관한 광고 내지 홍보 내용 등을 종합적으로 고려해야 한다.

(투의물효/속새구)

투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다.

(의자투/시물)

i) 의사는 그의 전문지식에 따라 자유롭게 투여용법·투여용량을 결정할 수 있어야 하고, ii) 이는 시간의 경과라는 요소를 포함하고 있어 물건발명으로서의 의약용도발명의 성격과 조화되기 어렵다.

(필본유비법)

i) 의약이 효능을 온전히 발휘하도록 하기 위해서는 투여용법·용량을 적절하게 설정할 필요가 있으므로 이는 의약용도와 본질이 같다. ii) 동일한 의약이라도 투여용법·용량 변경에 따라 예상하지 못한 유리한 효과를 발휘할 수 있으며 이에 상당한 비용 등이 소요되어 이러한 투자의 결과를 특허로써 보호하는 것이 특허법 목적에 부합한다.

(투진/통시상/예현이)

투여용법과 투여용량에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원시 기술상식에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

(개적투노통)

의약개발과정에서 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위해 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로

<컴퓨터프로그램발명>

(소정하구)

소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우 발명의 성립성을 인정한다.

(하작물변야)

i) 하드웨어인 장치를 작동하게 하는 것일 뿐만 아니라 ii) 하드웨어의 물리적 변환을 야기시켜 그 변환으로 인한 실제적 이용가능성이 명세서에 기재되어 있는 경우 성립성을 인정한다.

<BM발명>

(영각컴수인기구/컴구구한)

영업발명의 각 단계가 컴퓨터 상에서 수행될 수 있도록, 인터넷·통신·컴퓨터기술 등 구체적 기술로 제시되고, 컴퓨터 상에서 구현되는 구성으로 한정하고 있는 경우 발명의 성립성을 인정한다.

(로클구연단)

발명의 성립성 인정여부는 청구항 전체로 판단하므로, 오프라인 상의 단계를 포함하더라도 로그인, 클릭 등 온라인상 구성요소를 연결하는 단순한 행위에 불과하다면 성립성 인정될 수 있다.

(과시엄)

BM발명은 그 발명이 속한 서비스 분야에서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높고, 이로써 시장질서의 훼손을 초래할 수 있다는 점에서 그 권리범위를 엄격하게 해석해야 한다.

<선택발명>

(선상하/중기활산)

선행발명의 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요소로 하는 발명. "중복발명에 해당하여 특허를 받을 수 없는 것임에도 기초발명의 활용을 촉진하여 산업발전을 도모하기 위하여 예외적으로 특허를 부여하는 것이다."

(선하구개/문존/통시상선존인)
선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하며, 구체적 개시는 i) 선택발명에 대한 문언적 기재가 존재하는 경우 뿐 아니라 ii) 통상의 기술자가 출원시 기술상식에 기초할 때 선행문헌으로부터 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

(기구예/현/구다방과이일)
부정설: 기술적 구성이 다르다, 긍정설: 선행발명의 구성요소를 모두 가지고 있다. 절충설: 원칙 이용관계 긍정하나 예측하지 못한 효과 있다면 부정
判例 선택발명이 선행발명에 비해 현저히 향상된 작용효과가 있어 기술적 사상을 달리하는 것으로 권리범위에 속하지 않는다.
검토: 등록요건 판단과 권리범위 해석은 구분되어야 하는 바 원칙적으로 이용관계 긍정하되, 다른 방식으로 과제를 해결하거나 전혀 이질적인 효과를 나타내는 등 선행발명과 일체성이 유지되지 않을 때 이용관계 부정.

(등법상/보효물미불)
신규성과 진보성은 i) 등록 이후의 법적취급이 상이하며, ii) 선택발명이 구체적으로 개시되었음에도 보호한다면, 보호범위가 그 효과에 한정되지 않고 물질 자체에 미치게 되므로 출원인이 발명한 것 이상을 보호하게 되어 불합리

(하모질다양현/효명질구양정)
선행발명을 구성하는 하위개념 모두가 선행발명과 질적으로 다른 효과를 갖거나, 동질이더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 진보성이 인정된다.
발명의 설명에는 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재해야 하며, 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

(특배부시/상일하확개)
i) 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, ii) 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우는 일반 발명과 같이 진보성을 판단하고, 효과에 대한 명세서 기재요건이 완화된다.

(일선마/상공구진)
일반발명의 진보성 판단기준은 선택발명의 진보성을 판단할 때도 마찬가지로 적용되어야 한다. 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다.

(선구효진)
선택발명이라는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단해서는 아니 된다는 점에서 최근 대법원 판례 타당.
(판례가 변경된 것은 아님!)

(이포개/통우쉽동/구특구)
i) 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화학식의 개수, ii) 통상의 기술자가 선행발명에서 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기, 암시의 유무, iii) 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려해야 한다.

(효선동구)
진보성을 판단할 때는 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려해야 한다. 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다.

(명통인추효의)
효과의 현저성은 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단해야 하고, 효과가 의심스러울 때는 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후 추가적인 실험자료를 제출하는 등의 방법으로 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것도 허용된다.

(여선모일충나)
선택발명에 여러 효과가 있는 경우, 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다. 다만, 나머지 효과가 적어도 선행발명의 효과와 비슷한 정도는 되어야 한다.

(효명비실의)
선택발명의 발명의 설명에는 선행발명에 비해 현저한 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 비교실험자료까지 기재해야 하는 것은 아니며, 그 효과가 의심스러울 경우 출원인이 구체적인 자료를 제출하는 방법으로 효과를 주장·입증하면 된다.

<수치한정발명>
(청발특필수표/기활산)
청구항에 기재된 발명의 특정에 필요하다고 인정되는 사항의 일부가 수량적 표현을 포함하는 발명. 기초발명의 활용을 촉진하여 산업발전에 이바지

(공구개/통주새효) (문존/통시상선범인)
한정된 수치범위가 i) 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, ii) 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 신규성이 부정된다.
구체적 개시는 i) 선택발명에 대한 문언적 기재가 존재하는 경우 뿐 아니라 ii) 통상의 기술자가 출원시 기술상식에 기초할 때 선행문헌으로부터 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다

(공상기이현/공구개/통주)
수치한정이 공지된 발명과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 이질적이거나 현저한 효과 차이가 생기는 경우 i) 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 볼 수 없음은 물론, ii) 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용 수단에 불과하다고 볼 수 없다.

(공한얻특비개)
i) 단순히 화합물의 순도를 한정한 것에 불과한 경우 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정되나, ii) 공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명이 한정한 순도의 화합물을 얻을 수 없고, 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시한 경우 신규성이 부정될 수 없다.

(이현통단)
한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용 효과 차이가 생기지 않는다면, 이는 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다.

(진다보/공상기이임)
i) 수치한정발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 수치한정이 보충적 사항에 불과하거나 ii) 수치한정이 공지된 발명과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 효과도 이질적인 경우라면 임계적 의의가 없다고 진보성이 부정되지 않는다.

(전실안/통시상/과특정없명)
수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원시 기술상식으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고 명세서 기재만으로 수치범위 전체에 걸쳐 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는 명세서 기재요건을 충족하지 못한다.

(범균/특한범)
범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 특별한 사정이 없는 한, 특허발명에서 한정한 범위 밖의 수치를 가지는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

(침특균/통단)
균등하다고 보기 위해서는 침해의심제품이 특허발명에 기재된 수치와 균등한 범위의 수치를 가지는 것이 밝혀져야 하고, 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하더라도 마찬가지이다.
(단순한 수치한정의 경우 균등론이 적용될 수 있기는 하나, 사안에서는 범위 밖의 수치 균등하지 않다고 봄)

<청구범위 해석>
(청제확/문발표기/객합)
判例 청구범위 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다
判例 문언의 일반적 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면을 참작하여 그 문언에 의해 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석한다

(청제확/문발객합/알표기확) (사실상 거의 같은데 표현이 조금 다름)
判例 청구범위 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다
判例 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석한다.
문언만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우, 명세서의 다른 기재에 의해 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 권리범위를 정하여야 한다.

<PBP청구항>
(물구방특/창표다)
물건발명을 구성이 아닌 방법에 의한 특정한 청구항. 창작표현의 다양화

(제특특/진제물)
제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 없는 한 진보성 판단에 있어 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 물건으로 특정되는 발명만 비교하면 된다.

(제한/제포/청모특구성물)
특허요건 판단함에 있어 기술적 구성을 제조방법 자체에 한정하여 파악할 것이 아니라, 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건으로 파악하여 판단해야 한다.

(본수)
발명의 대상은 제조방법이 아닌 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 PBP청구항의 본질은 물건발명이고, 제조방법은 물건의 구조나 성질을 특정하는 수단에 불과하다.

(제한/제포/청모특구성물/권실지불)
특허요건 판단함에 있어 기술적 구성을 제조방법 자체에 한정하여 파악할 것이 아니라, 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건으로 파악하여 판단해야 하고, 이는 권리범위에 속하는지 여부 판단함에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 다만, 특허발명의 권리범위가 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등 명백히 불합리한 사정이 있는 경우 권리범위를 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

<기능식청구항>
(청기포/창표다)
청구항에 소위 기능적 표현을 포함하는 청구항. 창작표현의 다양화

(기모/청용특발/용일표기/용객합확)
발명의 내용은 청구범위에 기재된 사항에 의하고, 청구범위를 제한하거나 확장해석하는 것은 허용되지 않으며 이는 기능적 표현으로 기재된 경우도 마찬가지이므로 기능을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석함이 원칙이다.
다만, 청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 발명의 설명에 설명되는 등 다른 사정이 있는 경우에는 용어의 일반적 의미를 기초로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정해야 한다.

(명알표기확)
청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도, 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 설명 등을 참작하여 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 권리범위를 정하여야 한다.

(모구포안/명확구포한)
권리범위는 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것이 아니라 청구항의 기재와 발명의 설명에 의하여 명확히 확정할 수 있는 구성만을 포함하는 것으로 한정 해석해야 한다.

청구항 차별의 원칙: 독립항의 권리범위를 종속항의 권리범위와 동일하게 해석하면 안 된다는 이론.
判例 특별한 사정이 없는 한 독립항의 기술내용을 독립항을 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 설명에 나오는 특정 실시례 등으로 제한하여 해석 할 수 없다.
다만, 문언만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우, 명세서의 다른 기재에 의해 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 권리범위를 정하여야 하고, 이는 독립항과 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.
검토: 청구항 설계 의사 고려할 때 가급적 청구항 차별의 원칙 관철. 다만, 보충해석이 필요한 경우까지 절대적으로 관철할 필요는 없음.

<젭슨청구항>

(전종인/특개추)

전제부에 종래기술을 인용한 후, 특징부에 개량되거나 추가된 구성요소를 기재하는 기재형식.

(문요기적/목다/전공근)

전제부는 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명의 적용물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다.

(기도선심공)

종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나, 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니므로 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수 없다.

(확지/객)

명세서의 기재위치에만 근거하여 공지된 기술로 간주하는 태도는 i) 공지에 관한 확인도 없이 출원인의 지식을 진보성을 부정의 이유로 삼아 부당하고, ii) 객관적 진실에 반할 우려가 있는 바

(전출공전/별공추) (착공잘번)

명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 공지기술이라는 취지로 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 다만, 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있으면 추정은 번복될 수 있다.

(추복절실)

자인에 근거한 사실상의 추정 및 복멸의 허용이라는 구도를 채택함으로써 절차적 효율성과 실체적 정의를 조화롭게 달성할 수 있는 바

<마쿠쉬청구항>

(상성2택)

상호 유사한 성질을 가지는 2 이상의 구성요소가 있는 경우 택일적으로 하나의 청구항에 기재하는 기재형식.

<특허권의 공유>

(조규/다본공)

특허권 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐 아니라 특허법에 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다.

(3지경변99/금규)

민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의해 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 변동이 발생한다고 보기 어려워서 99조 2항, 4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로 특허권 공유관계에 민법상 공유물 분할청구에 관한 규정이 적용된다.

(현동복부)

현물분할을 인정하게 되면 하나의 특허권이 사실상 그 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 아니한다.

----------제3장 특허요건----------

<발명의 성립성>

완성된 발명 의미와 판단방법 **(통반목구객/목구효실한)**

i) 통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성가능성을 '예상할 수 있을 정도로' 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.

ii) 청구범위를 기준으로 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과를 전체적으로 고려하여 판단하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다. (2017후523)

(미자통/경용기파)

미완성 발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의해 용이하게 기술내용 파악이 가능하다면 신규성 또는 진보성 판단의 인용참증이 될 수 있다.

<특허받을 수 있는 권리>

(착목조/기창실기)

발명자에 해당한다고 하기 위해서는 i) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, ii) 발명의 목적·효과를 달성하기 위한 구체적인 수단의 제공 또는 iii) 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 iv) 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하여야 한다.

(변상/변통부차/기창실기)

구성을 일부 변경함으로써 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되더라도 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 않고 그로 인한 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 무권리자의 출원으로 본다.

(양권귀/출설무무)

i) 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 권리의 귀속주체가 아니므로 ii) 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

(3승양법/무무양3)

i) 38조1항의 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하므로, ii) 무권리자의 특허로서 무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 38조1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

38조 1항은 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우위를 정함에 있어 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 취지.

<공동발명>

(발완실상협/착목조/기창실기/보관자)

i) 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적 상호협력하는 관계에 있어야 하므로 ii) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, iii) 발명의 목적·효과를 달성하기 위한 구체적인

수단의 제공 또는 iv) 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 vi) 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하여야 한다. vii) 따라서 단순한 보조자, 관리자, 자본주 등은 공동발명자가 될 수 없다.

<산업상 이용가능성>

(실장기장)

실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐, 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.

(인수치진)

의료업의 산업상 이용가능성은 인체를 필수 구성요소로 하는지 여부가 판단기준이 되며, 인간을 대상으로 한 수술방법, 치료방법, 진단방법은 산업상 이용가능성이 부정된다.

비치료적 용도

특判 i) 인체를 처치하는 방법이 치료효과와 비치료 효과를 동시에 가지는 경우에 ii) 치료효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없으면 iii) 그러한 방법은 치료방법에 해당하므로 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다. iv) 특허대상에서 제외되는 치료방법 등이 반드시 의료법상 의료인에 의해 수행되는 것으로 제한되지 않는다.

<발명의 동일성>

(기구동/효참판)

두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단한다.

(차과구주새효미)

기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용 기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일하다.

(차과구주새효미+)

기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용 기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일하다.

위와 같은 정도를 벗어난다면 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명은 동일하다고 할 수 없다.

(통차)

구성의 상이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우 양 발명은 동일하다.

(대실양범곧)

동일성 판단은 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

<신규성>

(통과공불)

i) 화학물질의 경우 통상의 기술자가 출원일 전 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 ii) 과도한 노력을 기울이지 않고 조성이나 성분을 알 수 없었다면 iii) 비록 공연히 판매되었더라도 iv) 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다.

(공증전작후작)

특허출원 전의 의미는 공지된 시점이 출원 전이라는 의미이지 공지된 사실을 인정하기 위한 증거가 출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 출원 후 작성된 문건에 기초하여 어떤 발명이 출원 전 공지된 것인지 여부를 확인할 수 있다.

<진보성>

(기모자연통)

출원시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인 (2008허8150)

(유결전기/구효)

출원발명이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우, 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이므로, 특유한 과제해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성이 갖는 특유의 효과도 함께 고려해야 한다.

(결암제/시상기과/통용결)

i) 인용기술을 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, ii) 그렇지 않더라도 출원시의 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등에 비추어 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

화학발명의 경우, 선행발명들을 결합하여도 그 효과가 발휘될 것인지 쉽게 예측하기 어려운 경우 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다.

(3 이상 선행기술 결합)

결합에 의하여 각 효과의 총계 이상의 증진된 효과를 낳지 못하는 경우 3개 이상의 선행기술을 결합하여 발명의 진보성을 부정할 수 있다.

(구배작/구시배중)

방법발명에서는 개별 구성요소의 배치순서가 작용효과에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적 배치순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다.

(특분구/당해용)

i) 비교대상발명의 기술구성이 특정산업분야에서만 적용될 수 있는 구성이 아니며, ii) 통상의 지식을 가진 자가 특허발명이 당면한 기술적 문제의 해결을 위해 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 상이한 기술분야라도 선행기술이 될 수 있다.

(일전통합인/배불다종)

제시된 선행문헌을 근거로 진보성을 판단하는 경우 i) 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 '통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을' 기초로 대비 판단하여야 하며, ii) 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는지 판단한다.

(명기알전사)
명세서에 기재되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

<선출원주의>
(동전살후거)
출원인이 동일한 경우, 경합출원이 '특허결정 전'이면, 36조는 살피지 않고 다른 거절이유가 없으면 특허결정. 경합출원이 '특허결정 또는 36조 거절결정 후'이면, 36조 거절이유 통지

(한무나유경) (구취소)
어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것은 아니다.
검토: 구체적 타당성, 협의제의 취지, 무효심결의 소급효

(명불공) (장소)
i) 특허권의 포기에 의해 경합출원의 하자가 치유된다는 명문의 근거가 없고, ii) 특허권의 포기는 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓여 법적안정성을 해칠 우려가 있는 점, iii) 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로 충분하지 아니한 점으로 미루어 하자가 치유되지 않는다.
검토: 특허권의 포기는 소급효가 없고 장래로 소멸함에도 하자 치유를 인정하면 결과적으로 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당

<확대된 선출원주의>
(일후동/선공심방)
출원발명이 당해 출원일 전에 출원하여 당해 출원 후 출원공개된 선출원의 최명도에 기재된 발명과 동일한 경우, 특허를 받을 수 없다.
선출원주의의 보완, 공유재산의 사유화방지, 심사청구제도의 효율화, 방어출원의 억제를 위함이다.

<발명의 설명>
(명공보내범)
명세서만으로 발명을 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것

(통시수과특생사/구실효예)
i) 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명의 기재에 의해 물건 자체를 생산, 사용할 수 있고, ii) 구체적인 실험 등에 의해 증명이 없더라도 '통상의 기술자가' 발명의 효과 발생을 충분히 예측할 수 있다면 기재요건을 충족한다.

<청구범위>
(출공권부부)
출원인이 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는데 취지가 있다.

(통청대발/시수발청확일)
i) 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 '사항'이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, ii) 출원시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 '개시'된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화 할 수 있다면, 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.

(통시상/특받명개판/사용기일판)
i) 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원시의 기술상식을 고려할 때 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, ii) 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단해서는 안 된다. (바람직하게는 判例)

<다항제>
(보2다주다)
보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항을 2 이상 기재할 수 있는 다항제를 채택하여 주변한정주의 하에서 발명의 다면적 보호
(종적삭번택2먼번)
1항: 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항을 기재 가능
2항: 청구항을 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재
3항: 삭제
4항: 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 기재
5항: 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재
6항: 2이상의 항을 인용하는 청구항에서 인용된 항은 다시 2이상의 항을 인용할 수 없다.
7항: 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재
8항: 각 청구항은 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호

----------4장 출원제도----------
<공지예외적용주장>
(원정분/원누분)
i) 공지예외 효과는 원출원 시 해당 절차를 정당하게 밟은 경우에만 ii) 분할출원에서 그 절차를 다시 밟아 승계할 수 있다는 것일 뿐, iii) 원출원 시 공지예외주장 절차를 누락했다면 iv) 분할출원에서 그 절차를 밟았다고 하더라도 공지예외 효과를 주장할 수 없다.

<보정>
(최동유/선안3)
최초 출원과 동일성을 유지하는 범위 내에서 보충·정정하는 것. 선출원주의 하에서 출원인을 보호하기 위함이다. 다만, 절차의 안정과 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위해 보정의 시기 및 범위에 제한이 있다.

(의심적신공강)
의견서제출기회 부여는 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익적 요청에서 비롯된 강행규정이다.

(통시상/명마이)
최초 명세서 등에 기재된 사항이란 i) 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, ii) 명시적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명서세 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

<보정각하>
(특보결행/지)
특정기간의 보정이 부적법한 경우 보정을 결정으로 각하하는 행정처분. 심사절차의 지연을 방지하기 위함이다.

(기거반배신)
이미 출원인에게 그에 대한 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위함.

(보신준비특)
(위와 같은 사안에서) 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발생되더라도 그러한 거절이유가 보정으로 청구항이 신설되거나 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인해 새롭게 발생한 것으로 볼 수 없다.

(반가지기보)
보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량의 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로, 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하기 위함.

(삭인종그/삭직간인종잘/종2인번택누/삭관없새)
청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우란, 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 기재불비가 발생한 경우 뿐 아니라, 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 기재불비가 발생한 경우도 포함된다.

삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생하는 거절이유는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함되지 않는다.

<조약우선권주장>
(당정우기/선국)
조약 당사국의 최선의 정규출원을 기초로 1년 이내 우선권주장출원을 한 경우, 동일발명에 대한 등록요건 판단은 기초출원일로 소급된다.
선출원자의 지위를 국제적으로 보호

<국내우선권주장>
(선우선/내누)
국내 선출원을 기초로 1년 이내 우선권주장출원을 한 경우, 동일발명에 대한 등록요건 판단은 선출원일로 소급된다.
내외국인 평등, 누적된 성과 보호

(참등편신/후선승) (절문)
특判 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 선출원에 기초한 우선권을 주장할 수 있는 자로 볼 수 없다.
判例 i) 38조 4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없는 바, ii) 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.
검토: i) 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 주는 것이 우선권주장제도의 취지에 부합하며, ii) 문리해석 상 특정승계인은 55조의 '특허를 받으려는 자' 및 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'에 해당한다고 봄이 타당하다.

(통시상/명마이)
최초 명세서 등에 기재된 사항이란 i) 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, ii) 명시적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명서세 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.
검토: 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 보정과 별다른 차이가 없으므로, 보정의 경우와 같은 관점에서 실체적 효력을 받는 발명의 범위를 해석함이 타당.

(우불거취유)
우선권주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 거절결정 하는 것은 위법하다.

----------제5장 특허권 및 실시권----------
(청구항별 이전)
i) 특허권의 충돌을 방지하는 것은 특허법의 안정적, 실효적 적용을 위한 기본원리에 해당하며, ii) 특허법은 이러한 기본원리를 견지하기 위하여 215조에서 99조 및 100조를 제외하고 있다.

<허가에 따른 존속기간연장>
특判 i) 기존에 허가된 의약품의 치료효과와 상이한 치료효과를 갖는 동시에 ii) 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질을 유효성분으로 제조한 경우 iii) 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 보아 존속기간 연장대상이 된다.

(통등누연무/신등) (합대)
判例 134조1항2호를 연장등록 무효사유로 규정한 것은 i) 통상실시권의 등록이 연장등록출원서의 필수적 기재사항 및 증명자료임에 비추어 그것이 누락된 채로 연장등록이 이루어지는 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지로 해석함이 상당하며, ii) 그 신청 당시부터 등록을 마치고 있어야 한다는 취지로 규정한 것은 아니다.
검토: 통상실시권은 단순히 특허권자와 실시자의 명시적·묵시적 합의만으로 발생하고, 통상실시권의 등록은 제3자에 대한 대항요건이라는 점을 고려할 때 타당.
(연장등록여부결정 등본 송달 전까지 통상실시권의 등록 및 그에 관한 증명자료 제출 이루어지면 연장등록에는 무효사유가 없다.)

(심보자진/허귀지단) (중하)
判例 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였더라도 다른 심사부서에서 절차가 계속 진행되고 있었던 경우, 그 기간 역시 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 지연된 기간으로 단정할 수 없다.
검토: 각 심사부서별 심사는 최종 허가에 이르는 중간과정으로서 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 볼 것인바

(유효용/약염차통) (대품)
학설: 제품설, 주성분설, 유효성분설
특判 존속기간연장된 특허권의 효력은 동일한 품목으로 취급되어 별도의 품목허가를 받을 필요가 없는 의약품 범위에만 미친다.
判例 i) 존속기간연장된 특허권의 효력범위는 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병 치료를 위한 유효성분, 치료효과 및 용도의 동일여부를 중심으로 판단하며, ii) 침해제품이 약학적으로 허용 가능한 염의 차이가 있더라도 이를 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 특허권의 효력이 미친다.
검토: 명문상 특허법 95조는 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 '품목'의 실시로 제한하고 있지 않는 바

<실시권 일반>

(의독묵)

i) 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 의무를 부담하여야 하고, ii) 단지 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하고 있다는 사정만으로는 독점적 통상실시권 설정계약으로 볼 수 없다. iii) 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간의 의사합치만 있으면 성립되고, 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다.

(독법/알침)

i) 독점적 통상실시권자가 얻은 이익은 특허권자의 독점적·배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당하고, ii) 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 이러한 이익을 침해하였다면 불법행위가 성립한다.

----------제6장 침해----------

<균등침해>

(주등실보)

주변한정주의 하에서 등가관계에 있는 기술도 보호범위에 포함시킴으로써 특허발명의 실질적 가치를 보호하기 위한 것이다.

(치비특)

치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다.

(청형추/발공/특해기기사핵실) (실선과) 1차구이김 (2012후1132)

과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

검토: 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하는 데 있으므로

(특허발명의 실질적 가치에 대한 실효적 보호)

(기기과넓좁/기공기사핵대) (선실보) 2차구이김 (2017후424)

과제해결원리를 파악할 때 i) 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할 것인지를 결정하여야 한다. ii) 다만, 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

검토: 선행기술과의 관계에서 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 해야 하므로

(선과특해침/특해기기사핵침) 양방향가압 (2018다267252)

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 i) 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 하고, ii) 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다.

(특특/기사핵침/균문구개) 양방향가압 (2018다267252)

기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되어 있거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 i) 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없으므로, ii) 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품에도 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, iii) 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(기마인/통별채)

변경된 부분이 i) 청구범위에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 인식될 수 있거나 ii) 통상의 기술자가 별다른 기술적인 노력 없이 그러한 구성의 변경을 채택할 수 있는 경우라면 요건을 충족한다.

<간접침해>

(직부권)

직접침해에 이르게 될 개연성이 큰 경우에 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 특허 침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위한 제도

(생발구일결모새/공가조)

127조에서 의미하는 생산이란 특허발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 특허발명의 구성요소 모두를 포함하는 물건을 새롭게 만드는 행위이며, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등 행위도 이에 해당한다.

(통경상실다/이실일가)

사회통념상 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적 다른 용도가 없어야 할 것이고, ii) 막연히 다른 용도로의 이론적, 실험적, 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우 다른 용도가 있다고 할 수 없다.

(입증책임)

判例 특허물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하는 것은 특허권자가 주장·입증해야 한다.

특判 공평의 원칙상 침해자가 다른 용도를 가진다는 구체적이고도 합리적인 주장·입증을 해야만, 비로소 타용도 없음에 대한 특허권자의 입증책임이 현실화 된다.

검토: 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란

(실의공3) (부이) (2017다290095)

방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 간접침해가 아니다. / (검토)

i) 실시권의 부당한 제약으로 인해 특허권이 부당하게 확장되는 결과가 초래될 수 있으며 ii) 실시료 책정 등을 통해 특허권자는 이미 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있다.

(본타일교따)

소모품이라도 i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, ii) 타용도로 사용되지 아니하며, iii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, iv) 물건 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, v) 특허권자 측에서 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 특허물건의 '생산'에만 사용되는 물건에 해당한다.

(새로운 구성요소 결합)

감광카트리지가 특허발명 물건의 생산에만 사용되는 이상, 확인대상발명이 감광카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다.

(미처예간/기형불)
특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의해 처벌한다면 형벌의 불균형성이 초래되므로 127조는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다.

<이용관계-이용침해>
(새요그일)
후발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하고, 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 발명으로서의 일체성이 유지되는 경우에 이용관계가 성립한다.
이는 선 특허발명과 동일한 발명 뿐 아니라 균등발명을 이용하는 경우에도 성립한다.

(일현요그)
촉매부가로 발명의 기술적 구성의 일체성이 상실되었다고 볼 수 없으므로, 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라도, 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다.

(선후선적무/법저선)
i) 상표권자가 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 후출원 등록상표를 선출원 등록상표권자의 동의 없이 사용하였다면 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 무효심결 확정여부와 상관없이 선출원 등록상표에 대한 침해가 성립한다.
ii) 특허권의 경우 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

(삭선정반)
검토: 98조에서 선출원 특허와의 저촉관계 규정이 삭제되긴 하였으나, 이를 저촉관계의 경우 선원권리자의 동의를 받지 않더라도 정당한 권리의 실시에 해당하는 것으로 보겠다는 반성적 고려에 의한 것으로 볼 수 없다.

<생략침해>
(유결전기/구독일결)
判例 특허발명이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 유기적으로 결합된 전체로서 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 구성요소 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소가 결여된 경우 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

<우회침해>
(출반목/기사핵구/주효)
i) 출발물질, 반응물질, 목적물질이 특허발명과 동일하고, ii) 제조방법도 기술적 사상과 핵심적인 구성이 특허발명과 동일하며 iii) 부가공정이 주지관용기술에 의해 용이하게 부가할 수 있는 공정에 불과하고 작용효과도 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어려우므로 특허발명과 상이한 발명이라 볼 수 없다.

<복수주체의 특허침해>
부정설: 구성요소완비의 원칙에 근거해 공동직접침해 인정할 수 없다
긍정설: i) 객관적으로 복수주체의 행위를 종합하여 판단하는 객관적 공동설과 ii) 객관적 실시행위뿐 아니라 주관적 공동도 요건으로 한다는 주관적 공동설이 있다.

(복다실인의전복하)
복수주체가 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사를 가지고, 함께 또는 나누어서 전체 구성요소를 실시하는 경우, 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 침해여부를 판단한다.
검토: 복수주체의 침해 문제에 대한 현실적 대응 필요성과 객관적 공동만을 요건으로 하는 경우 공동 직접 침해의 성립 범위가 지나치게 넓어지는 문제를 고려할 때 주관적 공동설 타당

(단다실지영단)
단일주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 영업상의 이익을 얻는 경우 영업상 이익을 얻는 단일주체가 단독으로 특허침해한 것으로 본다.
검토: 실시행위의 주체를 규범적으로 평가하여 특정 주체에게 직접침해의 성립을 긍정하는 데 유용

(국주반/하수가예/가사유결일작/예) (2019다222782)
i) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ii) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, iii) 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태라면, iv) 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것으로 본다.

(추가결구/단지일처/유결일작)
i) 그 발명에서 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, ii) 개별 물건이 단일 주체의 지배관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 iii) 사회적, 경제적 측면에서 보았을 때 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태인 경우, 그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 본다.

<공정력과 判例의 제항변>
(일무확유다당)
특허권이 일단 등록된 이상 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다.

(무확전/진부무명/항전심) (공목형)
判例 특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라도 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 특허권에 기초한 침해금지 등 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않고, 침해소송 담당 법원으로서도 권리남용의 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 진보성 여부에 대해 심리·판단할 수 있다.
검토: 진보성 없는 특허발명에 대해 독점·배타권을 인정함은 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐 아니라, 특허법의 입법목적에 배치되고, 특허권자에게 부당한 이익을 주고 실시자에게 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자 사이의 형평에 어긋난다.

(정정의 재항변)
判例 권리남용의 항변이 있는 경우, 특허권자는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 재항변으로 주장할 수 있다.
검토: 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정을 재심사유로 인정할 수 없는 바, 사실심 변론종결 전에 특허권자에게 충분한 방어 기회 부여

(확목본무) (준주)

判例 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지를 확인하기 위한 절차로서, 진보성 여부를 권리범위확인심판에서 판단하는 것은 i) 권리범위확인심판 제도의 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않으며, ii) 무효심판의 기능을 약화시키는 것이므로 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정해서는 안 된다.

검토 i) 특허무효심판과 권리범위확인심판의 특허심판원 내 절차 준별의 필요성, ii) 신규성 판단과는 달리 고도의 주관적 판단을 요하는 진보성 판단에 의해 권리범위를 부정하게 함은 부당하므로

<자유기술항변>

(공공용필)

특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않게 된다.

(애없균확) (본기대일적) (무분)

특判 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로 문언침해의 경우에는 적용되지 않는다.

判例 자유실시기술의 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해여부 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 문언침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

검토: 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 당사자 간의 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다는 점에서 자유기술의 항변은 특허무효의 항변과 별도의 존재 의의가 있다.

(자청한전)

확인대상발명이 자유실시기술인지 여부 판단할 때, 청구범위에 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명 구성 전체를 가지고 판단한다.

<의식적제외이론>

(출일권배/금확제3)

출원인의 의견 표명에 대하여 일정한 요건 아래 '의식적 제외'로 인정하고 특허발명의 권리범위에서 배제되는 것으로 보는 법리. 금반언의 원칙에 근거해 보호범위의 지나친 확대 해석을 방지하고, 제외 의사를 신뢰한 제3자를 보호

(명심출보의/출청감사/출구권제) (엄균실유)

의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서 뿐만 아니라 심사관이 제시한 견해, 출원과정에서 보정서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다.

i) 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, ii) 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다.

검토: 엄격한 규준에 의하면 사실상 균등침해가 인정되기 어려워 실효성이 없을 것이므로 유연한 규준이 타당.

(균용기만)

출원인이 출원 시에 균등 여부가 문제되는 침해 제품 등의 구성을 용이하게 생각해 낼 수 있었음에도 그것을 청구범위에 기재하지 않은 경우에도 그것만을 이유로 위 구성이 의식적 제외된 것으로 볼 수 없다.

cf. 일본判: 발명의 설명이나 출원시 발표한 논문이 다른 구성을 기재하고 있는 경우 의식적 제외 인정

<권리소진이론> *

(방실구물목효)

특허권자 등이 방법발명을 실질적으로 구현한 물건을 적법하게 양도한 경우, 방법발명의 특허권은 목적을 달성하여 소진되었으므로, 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대해 특허권의 효력이 미치지 않는다.

(실회)

방법발명과 물건발명은 실질적으로 동일한 경우가 적지 않다는 점에서 방법발명을 소진대상에서 제외할 합리적 이유가 없으며, 오히려 방법발명을 청구항에 삽입함으로써 특허권 소진의 적용을 회피할 수 있게 되는 문제가 발생할 수 있다.

(통본다/기사핵구/공전비)

i) 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부 ii) 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부 iii) 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

<특허괴물>

(외행실취목/목내공)

i) 부당한 행사는 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, ii) 이는 특허법의 목적과 취지, 특허권의 내용, 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향을 고려해 판단한다.

(부당한 경고장 발송행위에 대한 불법행위 책임)

(자법/발신)

i) 경고장 발송행위는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, ii) 권리자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

(직손/세주)

i) 제3자에게 침해를 이유로 거래중단 등을 요구할 때는 침해자에게 직접 경고할 때보다 침해자에게 손해를 입힐 가능성이 크므로, ii) 더 세심하고 수준 높은 주의가 필요하다고 판시하며, 경고장 발송행위로 인하 불법행위를 인정한 바 있다.

<손해배상청구>

(시상광품침/침경)

i) 침해자의 시장 개발노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 침해와 무관한 판매수량이 있는 것으로 ii) 특허권 침해하지 않으면서 특허제품과 시장에서 경쟁하는 제품 있다는 사정 포함한다.

(액발/염개주/동)

손해액을 추정하는 것일 뿐 손해발생까지 추정하는 취지라고 볼 것은 아니므로, 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없다. 다만, 손해발생은 경업관계 등으로 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하고, 특허권자가 침해자와 동종영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 손해발생이 사실상 추정된다.

(전침관기)
물건의 일부가 침해에 관계된 경우 또는 침해한 특허기술 이외의 요소가 판매이익에 기여한 경우, 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 한다.

(불중격양)
기여율은 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가한다.

(특창전액)
특허는 상표와 달리 기술적 사상의 창작을 보호 객체로 하는 것인 만큼 특허권자가 전혀 실시하지 않는 경우에도 실시료 상당의 손해배상액을 청구할 수 있다고 볼 것이다.

(가실동/잔이대침/객합)
특허발명의 기술적 가치, 제3자와의 실시계약 내용, 동종 특허발명의 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 이용형태, 대체기술의 존재 여부, 침해자가 얻은 이익 등 변론과정에서 나타난 여러가지 사정을 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정해야 한다

(실불특참입)
특허권자가 제3자와 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면, 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용 하는 것이 현저히 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하며, 유추적용이 현저히 불합리하다는 특별한 사정은 그러한 사정을 주장하는 자가 입증해야 한다.

(발인자폐)
손해발생은 인정되나 그 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 손해액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우 128조 7항을 적용할 수 있다.

(자변증상)
'자유로이 합리적인 방법'을 채택하여 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.

(자근탐객)
본 규정은 법관에게 손해액 산정에 관한 자유재량을 부여하는 것은 아니므로 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 탐색해낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 '객관적으로 수긍할 수 있는 손해액'을 산정해야 한다.

(존권)
과실이 없다고 하기 위해서는 i) 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정 또는 ii) 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정을 주장·입증해야 한다.

(제정실/과정그)
i) 특허침해 제품을 생산·판매한 후에 특허발명의 청구범위 정정심결이 확정되었더라도, ii) 청구범위에 실질적인 변경이 없으므로, iii) 특허권 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다.

(처침권)
i) 133조3항에 의해 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, ii) 침해 당시 실시발명을 자신의 특허권에 기해 제작한 것이라고 믿었더라도 iii) 실시발명이 등록특허의 권리범위에 속하지 않는다고 믿었던 점을 정당화 할 수 있는 사정에 해당한다고 할 수 없다.

<벌칙>
(대등/태다구) (능방)
判例 형사소송법 254조 4항에 따라 i) 침해의 '대상'과 관련 특허등록번호를 기재하여 침해된 특허발명을 특정하고, ii) 침해의 '태양'과 관련 침해제품의 제품명, 번호, 구성 등을 기재하여 침해제품을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정해야 한다.
검토: 소송의 능률과 신속을 꾀함과 동시에 피고의 방어권 행사 보장

(특표청변/변통부차/공오)
특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라도, 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 않고 그로 인한 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에 허위표시에 해당하지 않는다.

다른 특허표시한 경우 判
이미 특허된 방법을 사용하여 제조하면서도 다른 특허의 방법을 사용하는 것처럼 표시하는 경우, 침해에 해당할지언정 허위표시에 해당하지 않는다.
(제3자는 특허번호가 아닌 특허라는 표시를 신뢰하므로)

----------제7장 심판----------
<심판의 주체>
(존불소직현)
특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자를 말한다.

<참가>
(청이당계종서)
i) 청구인적격 (당사자참가) 또는 심판결과에 이해관계 가진 자가 (보조참가) ii) 당사자계 심판에 대해 iii) 심판절차 계속 중 심리종결 전에 iv) 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.

(속일중)
i) 당사자 참가인은 피참가인과 동등한 법률상지위를 가지며, 피참가인이 심판청구 취하한 후에도 심판절차를 속행한다.
ii) 보조참가인은 일체의 심판절차를 수행할 수 있으나 피참가인에게 종속되어 피참가인이 심판청구를 취하하는 경우 지위를 상실한다.
참가인에게 심판절차의 중단·중지 사유가 있는 때에는 피참가인에게도 효력이 발생한다.

<일사부재리>
(남경반)
심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제를 도모하고, 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 한다.

(청각/확번유증각)
i) 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우 163조 단서에 따라 일사부재리 효력이 없다. ii) 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후 동일증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다.

(2001/각기문/심3)
i) 2001년 개정법에서 각하심결에 대해 일사부재리 효력이 없음을 명확히 하였고, ii) 각하심결을 본안심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다. iii) 심판청구권 보장 역시 중요한 가치이고, 현행 163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 단서의 예외를 인정하여 적용범위를 확대하는 것은 정당화하기 어렵다.

(형중쟁거/확번유/쟁)
형식증거설: 형식적으로 완전히 동일한 증거
중요중거설: 확정심결을 번복할 정도로 유력하지 않은 증거도 포함
쟁점증거설: 전심에서 문제된 쟁점과 관련된 증거
증거동일설: 내용이 사실상 동일한 증거
判例 "동일증거는 확정된 심결의 효력을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다"고 판시하여 중요증거설의 입장이다. 다만, 최근 특허법원은 쟁점증거설과 유사한 입장을 판시한다.
검토: 중요증거설과 같이 확정심결을 번복할만한 증거가치를 판단기준으로 하되, 확정 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉한다고 볼 수 있는지를 합리적으로 판단하는 것이 타당하다.

(그심판사/확번유보결) (2012후1057)
i) 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나, ii) 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우와 같이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.

심판편람: 무효심판절차에서의 정정이 부적법하다는 이유로 정정무효심판을 청구하는 경우 일사부재리 법리를 적용하여 심결각하.
判例 명시적인 판시는 없으나, 무효심판 내의 정정청구와 이후의 정정무효심판은 동일 절차가 아니므로 일사부재리가 적용되지 않는다는 전제하에 본안심결을 한 바 있다.
검토: 무효심판 내 정정청구에서 항상 당사자 대립구조에 의한 심리가 이루어지는 것은 아니므로 判例 타당.

(심우재/법판무)
종래判例 일사부재리 위반여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다.
전합判例는 i) 일사부재리 위반여부를 심결시를 기준으로 판단할 경우 ii) 다른 심판의 심결 확정이라는 우연한 사정만으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권이 과도하게 침해될 우려가 있고, iii) 특허법원의 판결을 무의미하게 만드는 불합리가 발생하므로 iv) 기준시점은 심판청구 제기 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정된 경우 당해 심판청구를 일사부재리 원칙에 의해 부적법하다고 할 수 없다.

(보사증심)
심판청구 후 심결시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

(명문3) (사증제보모)
i) 명문이 '그 심판을 청구할 수 없다'라고 규정한 163조의 문언해석에 따르면 선행심결확정의 판단시점을 심판청구시로 보아 제3자의 권리 제한을 최소화함이 타당하다.
ii) 다만, 심판청구인은 140조2항2호에 의해 청구의 이유로서 사실 및 증거를 제한 없이 보정할 수 있는 바, 심결시를 기준으로 동일사실 및 증거를 제출한 것인지 판단함으로써 심결의 모순·저촉 회피라는 일사부재리 원칙의 취지를 조화롭게 달성.

(다무사/원공일확번유)
종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 않는다.
다만, 청구원인이 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리 원칙 위배여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지 판단해야 한다.

(심사증/주새무)
심결시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하며, 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 무효사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다.
검토: 반대견해가 있으나, 일사부재리 위반으로 부적법한 심판청구를 사후적으로 소급하여 적법하게 하는 주장을 허용하는 것은 부당하다.

<중복심판청구금지>
(259/남모경)
민사소송법 259조를 준용하여 중복심판청구를 명문으로 금지하였다. 이는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉 방지, 심판절차의 경제 도모를 위함이다.

(심소취확)
i) 전 심판 계속 중을 심판원 계속 중으로 해석하면 ii) 심결취소소송을 제기한 후 다시 동일한 심판청구를 할 수 있게 되어 iii) 중복심판청구금지 취지에 반하므로 iv) 전 심판에서 내려진 심결이 확정되지 아니한 경우를 의미한다.

(민소변특청심/일요범차)
i) 민사소송에서 중복제소금지는 소송요건으로서 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하므로, 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로서 심결시를 기준으로 판단하여야 한다.
ii) 중복심판청구금지는 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에서 차이가 있으므로, 심판청구시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

(회공일/공심전제)
i) 중복심판청구나 일사부재리 적용을 회피할 수 있다는 공백이 발생하는 문제점이 존재하나 이는 일회적인 것에 불과하며, ii) 위와 같은 불가피한 공백을 메꾸는 것이 심판청구가 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다.

(심판청구권 남용)
민사소송절차에서 패소한 당사자가 동일 당사자를 상대로 동일 청구에 대하여 다시 소를 제기하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 이를 권리남용 또는 소권남용으로 의율하지는 아니한다.

<거절결정불복심판>

(심거공절속)

거절결정을 받은 자가 심사관의 거절결정에 대해 심판원에 불복심판을 청구할 수 있다. 심사의 공정성 확보 및 당사자의 절차이익을 보장하기 위함이다. 심사에 대한 속심적 성격을 갖는다.

(절보강/의새)

i) 절차적 권리를 보장하는 특허법 규정은 강행규정이므로, ii) 의견서제출기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정불복심판을 기각한 심결은 위법하다.

(거심거통)

i) 거절결정이유 중 심사관이 통지하지 않은 거절이유가 일부 포함되어 있더라도, ii) 심결이유가 심사관이 통지하지 않은 거절이유를 들어 iii) 거절결정을 유지하는 경우가 아닌 한, iv) 위와 같은 통지 흠결의 사유만으로 기각심결을 위법하다고 볼 수 없다.
(거절결정에 절차적 위법사유가 있음은 별론, 심사관이 통지한 거절이유를 들어 거절결정을 유지한 이상 기각심결은 위법하다고 볼 수 없음)
(거절결정의 절차적 위법여부 별도 목차 가능)

(심거심심)

i) 심사단계에서 거절이유를 통지한 사유라도 ii) 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 iii) 심판절차에서는 '거절결정의 이유와 다른 거절이유'에 해당하므로, iv) 특별한 사정이 없는 한 심결의 이유로 하기 위해서는 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지해야 한다.

<무효심판>

(특무심/공완)

특허에 133조1항 각호에서 규정한 무효사유가 있는 경우 그 무효를 구하는 심판을 청구할 수 있다. 심사의 공정성과 완전성을 사후적으로 보장.

(존불소직현제판포/대없소)

전합判例 i) 이해관계인이란 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함되며, ii) 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

(실제시비불)

i) 실시권자는 무효심결을 통해 실시료 지급 등의 제약에서 벗어날 수 있고, ii) 무효심판의 절차에 소요되는 시간, 비용 및 불확실성을 고려할 때 실시계약의 설정을 무효여부를 다투지 않겠다는 의사표시로 단정할 수 없다.

(계원불상/무확불상)

특허무효의 소급효에도 불구하고 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그 때부터 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다.

(계원불상/계자별무)

실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료 지급을 청구할 수 있다.

실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 기지급 받은 실시료 중 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 부당이득으로 반환할 의무가 없다.

<권리범위확인심판>

(확속공/분조)

확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부를 공적으로 확인하기 위하여 청구하는 심판이다. 소송절차에 앞서 분쟁을 조기해결하고, 침해소송에서 법원의 판단기준을 제공하기 위함이다.

(권효대구)

권리범위확인청구는 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이다.

(성장물업)

소극적권리범위확인심판을 청구할 이해관계인에는 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로서 제조, 판매하리라고 예상이 되는 자도 포함된다.

(현소/현목적소익/상)

학설: 현존하는 경우에만 vs 소멸한 이후에도
判例: 권리범위확인심판은 현존하는 특허권의 범위 확정을 목적으로 하므로 특허권 소멸 후에는 그 확인의 이익이 없다고 하여 존속기간 중에만 가능하다.
나아가 상고심 계속 중 존속기간 만료 또는 무효심결 확정됨으로써 특허권이 소멸된 경우도 달리 볼 것이 아니다.

주제별 논의

I. 적극적 권범심 계속 中 소극적 권범심 청구

(법현장)

청구인의 법률적 지위에 현존하는 불안이 존재하고, 권리범위확인심판이 이를 해소하기 위한 가장 유효적절한 수단인 경우 확인의 이익이 인정된다.

(민별/오자)

특判 i) 민사소송과 동일한 정도 확인의 이익 요구된다고 보기 어려운 점, ii) 각각 별개의 독립한 심판절차로 취급되고 있는 점에서 심판청구의 이익이 있다.
검토
i) 타인이 청구한 심판 결론이 오판일 가능성도 배제할 수 없는 점
ii) 자신이 주체가 되어 별도 심판을 청구하여 새로운 판단을 받을 필요도 인정되는 점

(일판확예)

특判은 경과규정상 판단하지 않았다. / (검토)
i) 적극적 권범심과 소극적 권범심 간 일사부재리 적용한 判例 존재하나
ii) 일사부재리 판단시점이 심판청구시로 변경된 점
iii) 증복심판청구는 아직 확정되지 않은 심결을 전제로 하고 있는 점
iv) 중복심판청구 규정의 도입이 예정된 시점에서 후청구의 심판청구의 이익을 인정한 상기 특判 취지를 고려할 때, 중복심판청구에 해당하지 않는 것으로 보는 것이 타당.

II. 확인대상발명의 특정

(전대차)

확인대상발명은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 확인대상발명의 구성을 전부 기재할 필요는 없더라도, 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적 구성을 기재해야 하며, 이는 특허발명의 구성요건과 대비하여 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다.

(대불일속)

특허발명의 구성요소에 대응되는 구성이 확인대상발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 수 있는 경우 확인대상발명이 특정된 것으로 보아야 한다.

(통다구일)

확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별할 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 하며, 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 일사부재리 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로 심판청구를 각하해야 한다.

(대수설도)

확인대상발명이 i) 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 ii) 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면에 의해 특정되어야 한다.

(통확설상명파)

통상의 기술자가 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.

(방실특확)

특허발명이 방법발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비하도록 심판대상의 발명을 특정하여 특허권 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.

(불당/생추)

判例 i) 불분명한 것을 구체화하거나, ii) 처음부터 당연히 있어야 할 구성을 부가한 것에 지나지 아니하여 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우 요지변경에 해당하지 않는다.

특判 당초 물건만으로 특정된 확인대상발명에 생산방법을 추가로 기재하는 확인대상발명의 보정은 요지변경에 해당하지 않는다.

III. 확인의 이익*

(피실다/심실익/사사)

확인대상발명이 피청구인이 실시하는 발명과 다른 경우, 심결의 효력은 피청구인이 실제 실시하는 실시발명에 미칠 수 없으므로 확인의 이익이 없어 부적법하다.

확인대상발명과 피심판청구인이 실시하는 발명의 동일성은 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 동일성을 인정한다.

(현실다/장주다)

소극적권리범위확인심판의 당사자들 사이에 i) 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, ii) 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.

(소유과부)

소극적권리범위확인심판을 청구하는 것은 소송경제에 비추어 유효·적절한 수단이라 할 수 없고, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에 해당하여 심판청구의 이익이 없다.

(판침기아/간특분조고/164별독인전)

i) 권리범위확인심판은 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만,

ii) 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능

iii) 제164조는 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정, 확인의 이익을 인정한다.

(성기/규내취)

i) 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능

ii) 특허법의 규정 내용과 취지

(심소소만/금신위) (범법)

특判 심결취소소송에서 확인대상발명 미실시 주장하는 것은 심판절차를 지나치게 형해화시키는 것으로서 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다.

判例 심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 소송단계에서 하였다는 사정만으로는 금반언 내지 신의칙에 위반된다고 볼 수 없으므로, 심판단계에서 확인대상발명 미실시 주장 하지 않았더라도 심결취소송에서 이를 심결의 위법사유로 주장할 수 있다.

검토: 심결취소송의 심리범위에 관한 법리 (무제한설)를 고려

IV. 등록된 특허발명의 권리범위확인심판 적격성*

(적무부/소속부)

선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하나, (2007후2766)

소극적권리범위확인심판은 인용되더라도, 청구인의 등록특허가 피청구인의 등록특허의 권리범위에 속하지 않음을 확정할 뿐이고 피청구인의 등록특허의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 부적법하다고 할 수 없다. (84후19)

(적무부/후특신달아)

특判 신규성이 부정되는 특허발명에 대해 보호범위를 인정할 수 없어 권리 대 권리 간 권리범위확인심판에 해당하지 않아 적법하다.

判例 권리 대 권리의 적극적권리범위확인심판은 무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하며, 이러한 법리는 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 그 적용여부가 달라지는 것은 아니다.

검토: 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 심판의 결과가 달라지는 것은 법적안정성에 비추어 부당

(이부확)

이용관계에 있어 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위 확인을 구할 수 있는 경우에는 등록권리간 적극적 권리범위확인심판이 허용된다.

V. 심결취소소송 소의 이익

(후확변익각/최기익)

종래 특허법원은 상표관련 사건에서, 심결 이후에 확인대상표장이 등록된 경우, 사실심변론종결시를 기준으로 심결을 취소할 이익이 없어졌다는 이유로 소각하판결을 하였으나,

최근 특허법원은 기각판결(본안판단)을 하였는바 소의 이익을 인정하는 태도를 취하였다.

(유적수/민상중수) (존기소)

특判: 다툼을 해결하기 위한 가장 유효, 적절한 수단인 민사소송의 본안 판결의 상소절차를 통하여 다투어야 할 것으로, 분쟁해결의 중간적 수단에 불과한 심결의 당부를 확정할 실익은 없다.

判例

i) 여전히 원고에게 불리한 심결이 유효하게 존속하고 있는 점,

ii) 확정된 민사판결은 심결취소소송에 대하여 법적 기속력이 없는 점,

iii) 심결 이후 상표권이 소멸되는 등 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 않는 점에 비추어 소의 이익이 있다.

<정정심판>

(불정/무권3)

특허발명의 명세서에 불완전한 것이 있을 때, 명세서에 대하여 정정을 구하는 심판. 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하기 위함이다. 다만, 제3자의 이익을 균형있게 조화시키기 위해 제한적 범위에서 정정을 인정한다.

(당정삭/실동경고)

정정명세서 등에 관한 보정은 i) 당초의 정정사항을 삭제하거나 ii) 정정의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다.

(무유/조신진)

136⑩은 무효부분을 포함하는 특허를 본래 유효로 되어야 할 범위 내에서 존속시키기 위한 것이므로 그 정정내용이 조약우선권 주장의 기초가 된 발명의 내용 또는 신규성, 진보성 판단에 제공되는 선행기술로서의 발명의 내용에 영향을 미칠 수 없다.

(복청하기일)

복수의 청구항에 대해 정정이 청구되더라도 이는 하나의 기술사상에 기초한 것으로 일체로서 정정을 구하는 취지라 해석되어 일부항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체에 대한 정정을 불허한다.

주제별 논의

I. 범위 및 대상

(명명/일모)

i) 청구범위 기재자체가 명료하지 않을 경우 그 의미를 명확하게 하거나, ii) 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 않거나 모순되는 경우 이를 통일하여 모순이 없도록 하는 것이다.

(기사보특/일모)

i) 청구범위는 발명의 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것인 바, 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 ii) 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 않거나 모순이 있는 경우라고 보기 어렵다.

(통시상/명마이)

'명세서 또는 도면에 기재된 사항'이라 함은 i) 명시적으로 기재되어 있는 것 뿐만 아니라, ii) 통상의 기술자가 출원시의 기술상식으로 볼 때 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함한다.

II. 실질적 확장·변경하지 않을 것

(실변형전실/목효변기반/전신3손)

i) 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 청구범위 자체의 형식적 기재뿐만 아니라, 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적 내용을 대비하여 판단하여야 한다.

ii) 정정 후 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명에 기재된 내용을 그대로 반영하여

iii) 정정 전 청구범위를 신뢰한 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없다면 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다.

III. 정정심판과 무효심판 관계

(정우바먼전)

i) 무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속 중인 경우에는 정정심판을 무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단해야 하는 것은 아니고 ii) 무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정 전 특허발명이다.

다만, 최근 전원합의체 보충의견은 무효심판 사건의 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서에 따라 판단해 달라고 요청한 경우, 정정사유의 구체적 내용 등을 고려하여 합리적으로 결정할 필요가 있다고 판시한다.

검토: 권리를 부당하게 연장하는 수단으로 악용될 수 있다는 점에서 반드시 정정심판을 먼저 처리해야 한다고 볼 수 없다.

(무확처대익)

무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 정정의 대상이 없어지게 되어 정정을 구할 이익도 없게 된다.

(일허일불/일무전부)

i) 정정사건에서 일부에 대해 정정을 허용하고 일부에 대해 정정을 불허하는 심결을 할 수 없지만 ii) 일부 항이 무효가 되는 경우 소 전체가 부적법해진다고 볼 수 없다.

(일무실)

검토: 일부 항이 무효가 되는 경우 정정 가능여부에 관해 실체판단에 나아갈 필요가 없어서 정정일체의 원칙에 반하는 문제가 생기지 않는다

(동전정변)

특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리 판단의 대상이 된다.

(136범불)

i) 136조 10항에 의해 '심결'도 정정 후 청구범위에 의해 심결된 것으로 보아야 하는 점, ii) 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 않는 점, iii) 무효심판청구인은 정정무효심판을 청구할 수 있어서 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점을 고려할 때 판례 타당.

(2005허10213 논거)

(삭처대익)
정정심결이 확정되어 청구범위 일부가 삭제된 경우, 그 부분에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것이므로 그에 대한 심결 취소를 구할 법률상 이익이 없다.

(확법구/사자행/다확소변)
확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말한다.

전합判 **(특기/특확변/모소변/소분지)**
전원합의체 다수의견은 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되더라도
i) 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고,
ii) 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며,
iii) 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 취지로 해석하기 어렵고,
iv) 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것을 방지하기 위해 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결은 민사소송법 451조 1항 8호의 재심사유에 해당하지 않는다.

(무가)
사실심변론이 종결되었다는 이유만으로 정정 후 명세서에 따라 무효사유가 제거될 수 있는 기회를 종국적으로 박탈하는 것은 특허권자에게 가혹 (좀 더 길게 쓰고 싶으면 다수의견 i), ii), iii) 반박 가능)

검토 **(지취가)**
정정심결의 확정을 재심사유로 인정하는 태도는
i) 캐치볼 현상으로 분쟁의 종국적 해결을 지연시키는 결과 초래하는 점,
ii) 판결에 대한 무제한적인 재심사유를 인정해 재심제도의 취지에 맞지 않고, 이를 통해 구체적 타당성이 실현된다고 보기도 어렵다는 점,
iii) 변론종결 이후 추가로 정정의 기회를 부여하지 않더라도 특허권자에게 가혹하다고 볼 수 없다는 점

IV. 기타

(후피소전)
判例 정정 후 청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수 없으므로 정정 전 명세서를 대상으로 판단한다.
검토: 행위시법주의 취지 및 청구범위는 특허 보호범위를 대외적으로 공시하는 규범적 효력이 있다는 점에 비추어 타당.

(취새/147133답정)
i) 취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 경우에는 ii) 새로운 심판의 청구가 있는 때로 볼 수 없으므로, iii) 147조 1항, 133조의2 규정에 의하여 심판장이 원고들에게 답변서 제출기회와 정정청구의 기회를 주어야 한다고 볼 수 없다.

(번새정우)
i) 취소판결에 따른 심판절차는 심판번호를 새로 부여하여 진행하는 것으로 새로운 심판의 진행으로 보아야 하고, ii) 정정심판을 우선하여 심리해야만 하는 것은 아니라는 점에서 정정청구 기회 주어야 한다.

<심결취소소송 당사자>
(유일소/전확차)
공동심판청구인들은 유사필수적 공동심판관계에 있으므로, 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기했다 하더라도 심결은 청구인 전부에 대하여 모두 확정이 차단된다.

(특변소/변제)
i) 특허 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 출원인변경신고를 하지 않은 상태에서 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자에 해당하지 않으며, ii) 소를 제기한 후 출원인변경신고를 했더라도 제소기간이 지난 후라면 마찬가지이다.

<심결취소소송 제소기간>
(5특행/제특특/심특)
i) 특허법 5조가 특허에 관한 절차와 행정청의 처분에 대한 소의 제기를 구별하여 규정하는 점, ii) '특허에 관한 절차'와 관련된 특허법의 제반 규정이 특허청이나 특허심판원의 절차와 관련된 사항만 정하고 있는 점에 비추어 iii) '심결에 대한 소'는 '특허에 관한 절차'에 포함되지 않는다.

(심특행/8170161)
i) 심결에 대한 소의 제소기간 계산에는 특허법이나 행정소송법에서 별도로 규정하는 바가 없으므로, ii) 결국 행정소송법 8조에 의해 준용되는 민사소송법 170조에 따라 민법 161조가 적용될 것이다.

부가기간 지정신청 취급
제소기간 연장을 위한 부가기간의 지정은 제소기간 내에 이루어져야만 효력이 있고, 단순히 부가기간 지정신청이 제소기간 내에 있었다는 점만으로는 제소기간이 당연히 연장된 것이라 할 수 없다.

<심결취소소송 심리>
(심당법사)
심결취소소송에서 심결의 위법성은 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단한다.

(직변/당주법변)
심결취소소송은 직권주의가 가미되어 있다고 하더라도 여전히 변론주의를 기본구조로 하므로, 직권조사사항을 제외하고 법원이 당사자가 주장하지도 않은 법률요건에 관해 판단하는 것은 변론주의 원칙에 위배되는 것이다.

(당판사주/법제심판/특의사주)
당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장 및 입증할 수 있고, 법원은 제한 없이 이를 심리 및 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.
다만, 거절결정불복심판 또는 정정심판의 심결에 대한 취소소송에서 특허청장이 심사 또는 심판단계에서 의견서제출의 기회를 부여한 적 없는 사유를 주장하거나 이를 이유로 청구를 기각할 수 없다.

(소기의)
i) 심결취소소송의 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이고, ii) 특허법원 기술심리관의 참여가 가능하여 전문성을 갖추었다는 점에서 원칙적으로 무제한설 타당. 다만, 의견서제출기회를 부여하는 63조, 170조가 강행규정인 점, 소송단계에서는 보정의 기회를 부여할 수 없는 점을 고려할 때 예외를 두는 것이 타당.
(정정심판의 경우, 136조 6항, 136조 11항 언급)

(주부통보)
심결취소소송 절차에서 특허청장이 비로소 주장한 사유라고 하더라도 심사 또는 심판단계에서 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부의 판단 근거로 할 수 있다.

(심비보주증)
심사단계에서 통지된 비교대상발명을 보충하여 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것이 아니므로 법원이 이를 진보성 부정 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.

(선보주증/기선기보)
정정심판을 기각하는 이유가 선행발명에 의하여 발명의 진보성이 부정된다는 취지라면 특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은 i) 선행발명을 보충하여 출원 당시 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, ii) 정정의견제출통지서에 기재된 선행발명의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다.

(공차인극섭발)
거절결정불복심판 또는 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

(필전판구내)
비록 소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판단계에서 진보성 부정의 근거로서 이미 제시된 선행발명을 그 결합여부나 결합관계를 달리 주장하는 것이라도 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단내용이 달라지고 그로 인해 출원인이 심사 또는 심판과정에서 의견서제출기회를 부여받지 못한 경우 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

<심결취소소송 종료>

(사법/새기증특/종동)
i) 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생하며, ii) '새로운 증거'가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등 특단의 사정이 없는 한 iii) 종전심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다.
('새로운 사실' 특허법원 판례도 있음)

(심채조판번충)
i) 심판절차 내지 소송단계에서 채택·조사되지 않은 것으로서 ii) 판결의 결론을 번복하기에 충분한 증명력을 가지는 증거

(새답상/상증심행)
i) 특허심판원은 취소판결이 확정되어 재심리할 때는 당사자에게 새로운 증거를 제출하고 이에 대한 답변서를 제출할 수 있도록 상당한 기간을 부여해야 하고, ii) 상당한 기간을 부여하지 않아 당사자들로 하여금 증거제출 기회나 심판절차에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 했다면 그 심결은 절차상 위법이 있다.

(163189판번충)
163, 189②에 비추어 심판청구인은 판결의 결론을 번복하기에 충분한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여받아야 한다.

(독정별확/무심확)
무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 독립된 정정심판청구와 달리 정정청구 부분만 별도로 먼저 확정되는 것이 아니라 무효심판 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다.

----------단문 ----------

(특허결정에 대한 불복)
判例 특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허결정을 받은 출원인은 특별한 사정이 없는 한 그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 상당하다

(형인생치)
기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로 인용하고 있는 구성요소 일부를 생략하거나 치환하는 형식의 청구항은 독립항으로 보아야 한다.

(통인/출의보예)
i) 통상의 기술자가 쉽게 인식할 수 있고, ii) 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 사항